

< 채점기준 >

문1.

1. 문제의 소재 (2점)

절차의 명확성과 안정성의 요청 때문에 민법상 의사표시의 하자에 관한 규정은 소송 행위에 적용되지 않음이 원칙. 다만, 소의 취하와 같은 소송행위가 사기 등 제3자의 형사상 처벌받을 행위로 인하여 행해 졌을 때, 소송법상 이에 대한 구제방법을 인정하는 것이 일반적인 견해임. 소취하의 무효를 주장하면서 변론기일 지정신청을 하는 방법과 다시 소유권이전등기청구의 소를 제기하는 방법을 생각할 수 있는데, 후자의 경우 재소금지에 해당하는 것은 아닌지의 문제가 있음.

2. 변론기일 지정신청(14점)

소의 취하가 형사상 처벌할 타인의 행위로 인하여 행해진 경우, 민소법 제451조 제1항 제5호의 규정을 유추 적용하여 그 효력을 부인할 수 있다고 보는 것이 판례와 다수설의 입장임. 이 때 유죄의 확정판결이 필요하다고 하는 입장(판례)과 불필요하다고 보는 입장(다수설)이 대립. 이에 따라 같은 민소법 제165조 제1항, 민소규칙 제67도 제1항에 의거하여 소송종료의 효과를 다투면서 기일지정신청을 할 수 있을 것임. 법원은 기일지정신청에 대하여 변론을 열어 신청사유에 대하여 심리한 뒤, 소의 취하가 무효라고 인정되면 본안에 관한 변론절차를 속행하고 소의 취하가 유효라고 인정되면 소송종료선언을 하게 될 것임.

3. 소유권이전등기청구의 소 제기(14점)

같은 본안에 대한 종국판결선고 후 소를 취하해 놓고서 다시 동일한 소(당사자와 소송물이 동일한 소)를 제기하게 되는 것이므로 재소금지에 해당되지 않는가라는 의문이 있을 수 있음. 그러나 후소가 전소와 동일한 소라 할지라도 전소와 권리보호의 이익을 달리할 경우에는 재소금지의 원칙이 부적용된다는 것이 판례 및 통설의 입장. 사안의 경우 을이 소 취하의 전제조건으로 하였던 금전지급의무를 이행하지 않음으로써 갑, 을간의 약정은 해제 또는 실효되는 사정변경이 발생하였음을 갑이 주장하면서 재소할 경우 이는 새로운 권리보호의 이익 내지 필요성이 인정된다 할 것임.

문2.

1. 결론 : 허용되지 않는다.

2. 이유 또는 근거

선택적, 예비적 병합의 경우, 병합된 여러 개의 청구는 동일한 절차에 불가분적으로

결합되어 있기 때문에 일부판결을 선고할 수 없다(통설, 판례). 사안에서와 같이 법원이 주위적 청구만을 배척하고 예비적 청구에 대한 판단을 하지 않은 경우 이는 재판의 누락이 아니라 판단누락으로 보는 것이 통설, 판례임. 즉 예비적 병합의 경우와 성질상 일부판결이 허용되지 않는 소송에서는 재판의 누락이 있을 수 없으므로 추가판결로 시정할 것이 아니고 병합의 성질상 하나의 전부판결이라고 볼 것이므로 판단누락에 준하여 상소로 다투어야 함. 따라서 이 경우 갑이 판단누락한 예비적 청구부분을 간편한 분쟁해결수단인 항소로 다투지 아니하고 이를 그대로 확정시킨 뒤 다시 별소를 제기한 것은 권리보호의 이익이 없어 부적법하게 되기 때문이다.

문3.

1. 문제의 소재 (5점)

기판력의 시점 범위, 표준시(사실심 변론종결시) 이후에 을이 건물매수청구권을 행사하면서 대금청구의 소를 제기하는 것이 기판력의 실권효 또는 차단효에 의해 금지되는가의 여부가 문제의 핵심임.

2. 학설의 입장 (5점)

실권설, 비실권설, 절충설(을이 매수청구권이 있음을 알았음에도 행사하지 않은 경우에는 실권되지만, 몰랐을 경우에는 실권되지 않는다)이 대립됨.

3. 결론 (10점)

건물매수청구권은 취소권, 해제권 등과 같이 소송물인 권리관계 자체에 부착된 권리가 아니고 이러한 권리를 언제 행사할 것인가는 권리자의 자유에 속하는 것이다. 또한 전소인 건물철거 및 토지인도청구의 소와 후소인 대금지급청구의 소는 그 소송물을 달리한다. 따라서 확정판결에 기하여 건물철거가 집행되지 아니한 이상 대금지급청구의 소는 허용된다.

문4의 (1)(2)

1. 결론 : 모두 허용되지 않는다.

2. 이유 또는 근거

피고가 상계항변을 제출하였을 경우에 자동채권의 존부에 대하여 비록 판결이유 중에서 판단하게 되지만 상계로써 대항한 액수의 한도 내에서는 기판력이 생긴다(민소법 제216조 제2항). 상계항변이 채택되어 인정된 경우 어느 범위에 관하여 기판력이 인정되는가에 관하여 현재 반대채권(자동채권)이 소멸되어 존재하지 않는다는 점에 기판

력이 생긴다는 견해와 소구채권(수동채권)과 반대채권이 함께 존재하였다가 그것이 상계에 의하여 소멸된다는 점에 기판력이 생긴다는 견해가 대립됨. 후자가 통설이지만 어떤 견해에 의하든 부당이득을 원인으로 한 재소가 금지된다는 점에 있어서는 동일함.

결국 사안(1)에서와 같이 원고인 갑이 반대채권이 당초부터 존재하지 않는다고 주장하면서 부당이득반환청구를 하는 것이나 사안(2)에서와 같이 피고인 을이 소구채권이 당초부터 존재하지 않는다고 주장하면서 부당이득반환청구를 하는 것은 기판력에 저촉되는 것으로서 허용되지 아니한다.

문5의 (1)

1. 결론 : 허용되지 않는다.

2. 근거

고의에 의한 명예훼손을 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 전혀 별개의 사실을 이유로 하는 영업방해에 의한 손해배상청구의 반소를 제기한 경우, 양소의 청구사이에 관련성이 없고 또한 본소에 대한 방어방법과도 관련성이 없으므로 반소의 요건을 갖추지 못하여 부적법하기 때문이다.

문5의 (2)

1. 결론 : 허용되지 않는다

2. 이유

반소의 요건 가운데 하나는, 반소가 본소에 대한 방어방법과 관련성이 있어야 하는 것인데 이에 해당하기 위해서는 방어방법이 현실적으로 제출되어야 하고 또한 법률상 허용되는 적법한 것이어야 한다. 따라서 사안에서와 같이 상계금지채권에 기한 원고의 본소청구에 대하여 피고가 상계주장 내지 항변을 하는 것은 민법상 금지되어 있으므로(제496조) 이러한 경우 이에 바탕을 둔 반소는 부적법한 것이 되기 때문이다.

